

2012년 제49회 변리사 2차시험 - 상표법 해설

■ 총평

49회 상표법 2차는 평이한 수준으로 출제가 되었습니다. 평이한 난이도의 문제의 경우, 수험생 대부분들이 논점을 놓치지 않는 것을 가능하므로 (1) 정확한 목차(제목) 및 답안의 논리, (2) 법조문의 명확한 표시, (3) 판례 및 사안 포섭, 및 (4) 정확한 결과 도출이 어느 때보다 중요하다 할 것입니다.

구체적 답안은 이하에서 설명드리며, 수험생 여러분 모두들 수고하셨습니다. 좋은 결과 있기를 진심으로 기원합니다.

- 윤형근 변리사¹⁾ -

1) 합격의 법학원, 상표법 전임강사 / 前 리엔특허법인 상표부/ 現 명지특허법률사무소 근무

■ 구체적 답안 해설

<제A-1문>2)

I. 논점의 제기 (4)³⁾

II. 설문(1) - 진정상품병행수입의 허용의 이론근거 및 허용요건⁴⁾

1. 진정상품병행수입 의의 (4)

2. 진정상품병행수입의 허용여부 (22)

(1) 견해대립 : 허용론(국제적 소진이론, 상표기능론)/ 금지론(파리조약 속지주의원칙)

(2) 判例

(3) 검토

(4) 보론: 입법례(파리협약 등) 및 국내법규(관세법 등)

3. 진정상품병행수입에 대한 요건 (10)

(1) 진정상품병행수입의 허용요건(判例)

(2) 사안의 해결

국내외 상표권자 동일, 진정상품으로 출처가 동일, 품질의 차이 없으므로 → 진정상품병행 요건 만족 O

4. 설문(1)의 해결 (4)

병의 영국으로부터 갑의 의류를 수입, 판매하는 행위가 진정상품병행수입에 의한 판매로 허용.

III. 설문(2) - 판매지 제한 약정위반과 관련한 병의 수입판매 행위 허용여부

1. 문제점 (3)

갑은 영국 및 미국의 동일한 상표권자

미국내 전용사용권자 을에 의해 적법하게 상표를 표시하여 유통

2) 진정상품병행수입의 전형적인 문제.

3) (숫자)는 제목을 포함한 답안작성시 대략적 답안 줄의 수

4) 문제에서 진정상품병행수입의 이론적 근거 및 허용요건에 관한 일반론을 논하라고 하였으므로, 의의, 취지, 견해, 판례를 명확히 하여 다른 사람들과 차별화가 필요함.

2. 판매지 제한 약정위반 (10)

(1) 판매지 제한 약정위반의 타국 수출은 진정상품 X의 견해(대구고법)

(2) 대법원 判例

(3) 사안의 경우

상표기능론의 입장에서 대법원 판례 타당. 약정 위반만으로 진정상품 병행수입이 위법하지 않음.

3. 설문(2)의 해결 (4)

을에 의해 미국에서만 판매되고 있는 갑의 의류를 병이 국내로 수입, 판매하는 행위는 허용O

IV. 결 론 (3)

<제A-2문>5)

I. 논점의 제기 (3)

제7조 제1항 제6호(상호, 국내저명성X), 제9호 내지 제10호 및 11호 후단(국내 인식/주지저명X)는 논점에서 배제 처리.

II. 갑의 출원상표에 대한 상표등록 가능성 및 이유

1. 제6조 제1항 제3호 (18)

(1) 의의(요건) / 취지

(2) 성질표시

- 'PREMIER' 문자 자체는 절대적 품질표시(지정상품 무관)

(3) 보통으로 사용하는 방법으로 표시

- 원칙

- 예외: (判) 문자인식력 압도

(4) 사안의 경우

문자 자체는 절대적 품질표시이나 문자인식력을 압도하는 특별한 식별력 구비 → 본호 해당 X

2. 제7조 제1항 제11호 (10)

(1) 의의(요건) / 취지

(2) 判例 - 리눅스 사건

(3) 사안의 경우

성질표시 인정X, 품질 오인 가능성 없음 → 본호 해당 X

3. 제7조 제1항 제12호 (16)

(1) 의의(요건)/ 취지

속지주의 원칙의 예외

(2) 수요자 인식

- 2007년 개정법 : 주지성 완화

(3) 상품의 범위

- 법문상 상품범위 무제한이나, 주류적 判例는 관련관계 요구.

5) 제6조 제1항 제3호 식별력, 제7조 제1항 제11호 품질오인, 제7조 제1항 제12호 보호 여부에 관한 문제로 난이도가 높지 않은 문제로, 역시 법조문, 요건, 판례를 적절히 언급하는 것이 중요함.

(4) 부정한 목적

- 심사기준 및 判例 / 특정인의 출처표시 상표의 완전 모방: 부정한 목적

(5) 사안이 경우

- i) 2012. 2. 1자 출원으로 특정인의 출처표시, ii) 최소한 견련관계 인정, iii) 모방상표로 부정한 목적 인정 가능성 높음 → 보호 해당 O

4. 소결 (2)

갑의 이 건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 따라 등록은 거절이 될 것.

III. 결 론 (3)

<제B-1문>6)

I. 논점의 제기 (4)

+ 서비스표와 상표(2조 3항)7)

II. 설문(1) - 선등록서비스표권의 소유형태(서비스표권의 공유)

1. 서비스표권의 공유 및 발생태양 (12)

- (1) 서비스표권의 공유 및 법적성질
- (2) 발생태양
- (3) 사안의 경우

하나의 서비스표권을 갑과 을(2인)이 공동으로 소유하는 서비스표권의 공유

3. 공유서비스표권(상표권)의 효력, 제한 및 위반의 효과 (10)

- (1) 적극적 효력
- (2) 소극적 효력
- (3) 공유서비스표권(상표권)의 제한 및 위반의 효과

III. 설문(2) - 거절이유 및 타당성

1. 7조 1항 7호 (8)

- (1) 의의/취지/상표법상 취급
- (2) 요건
- (3) 사안의 경우

갑과 을의 공동명의 등록서비스표가 본호 소정의 인용표장 해당 여부(타인 해당여부, 서비스업과 상품의 동종유사성)가 문제.

2. 타인 해당여부 (6)

- (1) 判例
- (2) 사안의 경우

갑과 을의 공동명의 등록서비스표과 비교시 타인 해당O

6) (1) 상표권의 공유, (2) 제7조 제1항 제7호, 상표와 서비스표의 관계, (3) 거절이유 대응조치에 관한 문제

7) 서비스표가 문제되는 경우, 항상 언급해야하는 조문!!(본 문제에서는 설문 (1)에서만 언급하여도 무방!)

3. 서비스업과 상품의 동종유사성 (8)

- (1) 원칙
- (2) 판단기준 및 判例
- (3) 사안의 경우

휘발유: 동종유사성 O / 자동차 백미러: 동종유사성 X

4. 출원일체의 원칙 (2)

5. 설문(2)의 해결 (4)

심사관은 갑과 을의 공동명의로 등록서비스표를 인용표장으로 하여 갑의 출원상표에 대해 7조 1항 7호의 거절이유의 통지를 할 것으로 거절이유는 타당.

IV. 설문(3) - 거절이유 극복하기 위한 조치

1. 7조 1항 7호의 타인 요건 극복 방안 (6)

- (1) 극복 근거: 7조 3항 단서(등록여부 결정시 기준)
- (2) 극복방안
 - 출원인 명의변경신청
 - 서비스표권의 을의 지분 양수

2. 출원일체 원칙(문제상품: 휘발유) 극복 방안 (5)

- (1) 삭제보정(휘발유)
- (2) 출원의 분할

자동차 백미러만 남기고 휘발유 상품에 대해 분할 출원시 ‘자동차 백미러’에 대해 등록이 되고, ‘휘발유’상품에 대해서 추후 동일 거절이유 지적시 상기 7조1항7호 타인요건 극복방안의 조치 고려 가능.

3. 거절결정불복심판(간단히 2)

상기 극복방안은 출원상표가 거절결정이 되더라도 거절결정불복심판을 진행하면 처리가 가능.(타인 극복은 심결시전, 삭제/분할은 심판청구 후 30일 이내:보정가능기간)

V. 결론 (3)

<제B-2문>8)9)

I. 서설

상표권 이전 의의, 오인혼동 방지 목적에 따른 제한

II. 이전의 태양 및 절차

1. 발생원인

2. 이전의 범위

III. 이전의 절차

1. 특정승계

권리이전 등록신청서

2. 일반승계

별도 절차x, 다만, 상속 기타 일반승계의 취지 신고 필요(56조 2항)

IV. 이전의 효력발생과 효과

1. 이전의 효력발생

56조1항1호, 56조2항, 64조

2. 이전의 효과

(1) 상표권 이전시 내용 및 하자 등이 동일성 유지하여 이전

73조1항2호, 3호 관련 판례: 物의 처분

(2) 부수적 권리 영향 없음. 5조의17(절차의 효력의 승계), 5조의18(절차의 속행)

V. 이전의 제한

1. 제한사유 (54조 관련)

(1) 유사 상품 (54조 1항 후단)

8) 상표권 이전에 관한 일반 단문임.

9) 일반 단문 작성시 주의점 ① 문제에서 요구하는 것 위주로 기술, ② 정확한 법조문 언급, ③ 문제에서 요구하는 것 이외 사항은 관련문제로 가능한 간단히 서술 가능

>> 따라서, 본 문제의 경우, 상표권 이전의 “특정적 절차/ 효과 / 제한” 위주로 목차를 잡도록 하여야 하며, 관련 법 조문은 정확히 꼭 언급!!!!

- (2) 공유 (54조 5항)
- (3) 업무표장, 7조1항1호의3-4 단서, 1항3호 단서 등록 상표권(54조7, 8항)
- (4) 단체표장권 (54조 9항)
- (5) 증명표장권 (54조 10항)

2. 이전제한 위반의 효과

73조1항4호 + 73조 5항, 7조 5항

VI. 결 론

요약 + 관련문제(상표권 분할 이전시 문제, 국제등록기초상표권의 이전(86조의35 1항, 3항))